

# 2015년 특허법 2차 시험 기출 해설

## -권구성 변리사-

### 총 평

1. 사례문제와 단문형 문제가 모두 출제됨
2. 기본서 등을 통한 기본이론정리(문제 1, 문제 3, 문제 4) 및 암기
3. 특허법의 법리 및 최신판례 이해(문제 2, 문제 4)
4. 미리 준비한 논점이 아닌 출제자가 묻는 논점을 명확하게 캐치하여 답안에 서술하는 것이 중요했을 것으로 사료됨. 소논점으로 배점들이 분산되어 있어 예상보다 평균 점수가 낮아질 수 있을 것으로 판단됨

## [문제 - 1]

### 1. 설문(1) - 외국어 특허출원의 번역문 및 청구범위

#### 1. 외국어 특허출원 제도 및 청구범위 유예제도

(1)구법 상에서는 출원서류는 국어로 작성하여야 한다는 ‘국어주의’를 고수하고 있어 특허제도의 국제 추세에 부응하지 못하고 있다는 문제점이 있었다. 개정법에서는 외국어(영어)로 기재한다는 취지를 출원서에 기재하는 경우, 이를 허용하는 외국어 특허출원 제도(§ 42의 3①)를 도입하였다.

(2)선출원주의 하에서는 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하게 되는바 출원을 서두르다 보면 발명의 적절한 보호범위를 정할 수 없는 문제점이 있었다. 개정법에서는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 특허출원 시 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있는 것으로 하였다.

#### 2. 국어번역문 및 청구범위를 제출할 수 있는 법정기간

##### (1) 국어번역문의 제출기간

①출원일 선점 후 국어번역문 제출을 의무화하여 외국어 출원의 경우 최선일로부터 1년 2개월 이내 명세서 및 도면의 국어번역문을 제출하여야 한다.

②다만, 3자가 심사 청구하여 최선일로부터 1년 3월 전 3자 심사청구 사실의 통지를 받은 경우(§ 60③), § 60③에 의하여 통지를 받은 날로부터 3월 및 최선일로부터 1년 2월 중 빠른 날까지 제출하면 된다(§ 42의 3②단서).

③분할출원 및 변경출원이 외국어 출원인 경우에는 최선일로부터 1년 2월이 지난 후에도 분할/변경 출원일로부터 30일이 되는 날까지 명세서 및 도면의 국어 번역문을 제출할 수 있다(§ 52⑤, § 53⑦).

##### (2) 청구범위의 제출기간

①원칙적으로 최선일로부터 1년 2월까지 청구범위를 작성하는 보정을 해야 하고 심사청구 시 청구범위를 첨부해야만 심사청구를 할 수 있다(§ 42의②본문, § 59②(1)). 국어번역문 제출기간과의 형평성 문제, 출원인 혼란 문제 및 출원공개 지연 문제를 방지하기 위해 상기 제출기간이 개정법에서 변경되었다.

②3자가 심사 청구하여 최선일로부터 1년 3월 전 3자 심사청구 사실의 통지를 받은 경우(§ 60③), § 60③에 의하여 통지를 받은 날로부터 3월 및 최선일로부터 1년 2월 중 빠른 날까지 청구범위를 작성하는 보정을 하면 된다(§ 42의 2②단서).

### 3. 국어번역문 및 청구범위를 제출하지 않은 경우의 조치와 이유

#### (1) 국어번역문을 제출하지 않은 경우

① i) 국어번역문을 제출하지 않은 경우, 그 기한이 되는 날의 다음날에 특허출원은 취하된 것으로 간주된다(§ 42의 3④). ii) 이는 국어주의의 예외로 인정되는 것이고 심사대상 및 공개대상의 미확정 등의 문제가 발생되기 때문이다.

② i) 상기 번역문 미제출에 따라 특허출원이 취하되는 경우, § 64②(2)에 따라 출원공개 대상은 아닌 것으로 취급된다. ii) 이는 당해 출원의 선원의 지위 및 확대된 선출원의 지위를 발생시키지 않음으로써, 출원인이나 3자가 동일한 발명으로 재출원하는 것이 가능하도록 하기 위함이다.

③ i) 국어번역문 제출 전에는 명세서 보정, 분할/변경출원 및 심사청구가 불가능하다. ii) 이는 원출원의 내용이 확정되지 않은 상태에서 보정, 분할/변경출원의 객체적 요건을 판단하는 것이 어렵기 때문이다.

#### (2) 청구범위를 제출하지 않은 경우

① i) § 42의 2③에 의하여 기한의 다음날에 당해 출원은 취하된 것으로 간주된다. ii) 이는 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부할 수 있는 것은 예외적인 것이고, 심사대상과 공개대상을 확정하기 어렵기 때문이다.

② i) 상기 청구범위 미제출에 따라 특허출원이 취하되는 경우, § 64②(2)에 따라 출원공개 대상은 아닌 것으로 취급된다. ii) 이는 당해 출원의 선원의 지위 및 확대된 선출원의 지위를 발생시키지 않음으로써, 출원인이나 3자가 동일한 발명으로 재출원하는 것이 가능하도록 하기 위함이다.

## II. 설문(2) - 영어논문 명세서와 그 국어번역문의 법적지위

### 1. 영어 논문 명세서의 법적지위

(1) 외국어 특허출원 명세서를 출원서에 최초로 첨부된 명세서로 보고 그 외국어 명세서 범위에서 보정할 수 있도록 하고 있다.

(2) 다만, 실제 심사에서 외국어 명세서 기준으로 보정의 적합성 여부를 판단하는 것은 대단히 어려운바 ①심사단계에서는 외국어 명세서와 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 보정을 하면 거절이유에 해당하고(§ 62⑤), 특허등록 후에는 외국어 명세서를 벗어난 보정만 무효이유에 해당하도록 하였다(§ 133①(6)).

(3) 외국어 국제특허출원의 타출원으로서 확대된 선출원의 지위도 외국어 명세서 범위로 변경하였다(§ 29⑤). 다만, 국어번역문을 제출하지 않은 외국어 국제특허출원에 대해서는 현행과 동일하게 확대된 선출원의 지위 부여되지 않는다(§ 29⑦).

(4)외국어 특허출원의 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원의 가능 범위도 외국어 명세서 범위로 변경하였다(§ 29⑤).

## 2. 국어번역문의 법적지위

(1)출원인이 국어번역문 또는 새로운 번역문을 제출한 경우에는 외국어 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(§ 42의 3⑤본문). 따라서 심사관은 국어번역문을 기초로 심사를 진행하는 한편, 외국어 명세서 또는 도면에 없는 사항이 추가되면 이를 무효사유로 하고 있다.

(2)최종 국어번역문 이전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 42의 3⑤ 단서)

(3)국어번역문에 오역이 있으면 명세서를 보정할 수 있는 기간(§ 47①)에 오역 정정이 가능하다. 다만, 정정된 국어번역문에 대해서는 명세서 보정 효과가 부여되지 않는다.

## Ⅲ. 설문(3) - 국어번역문의 제출기간이 경과한 후, 甲이 취할 수 있는 조치와 그 법적 효과

### 1. 문제점

(1)국어번역문의 제출시기 이전의 경우에는 i)명세서 또는 도면을 보정하거나 ii)출원인이 심사청구를 한 경우를 제외하고는 미리 제출한 국어번역문에 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다(§ 42의 3③).

(2)그러나 사안에서는 국어번역문의 제출기간이 경과하였으므로, 甲의 국어 번역문 오역의 정정(§ 42의 3⑥) 조치를 살핀다

### 2. 甲의 조치 - 국어 번역문 오역의 정정(§ 42의 3⑥)

(1)국어번역문에 오역이 있으면 명세서를 보정할 수 있는 기간(§ 47①)에 오역 정정이 가능하다.

(2)따라서 i) “인지시간이 2~5초” 로 잘못 기재된 것을 파악한 甲은, ii)명세서를 보정할 수 있는 기간(§ 47①) 내에 “인지시간이 2~5초” 를 “인지시간이 3~5초” 로 변경하는 오역의 정정을 할 수 있다.

### 3. 법적 효과

(1)국어번역문에 오역이 있으면 § 47① 기간 내에 오역 정정이 가능하나, 정정된 국어번역문에 대해서는 명세서 보정 효과가 부여되지 않는다.

(2)따라서 甲은 별도로 “인지시간이 2~5초” 를 “인지시간이 3~5초” 로 변경하는 보정서를 별도로 제출하는 경우, 보정의 효과가 부여된다.

#### Ⅳ. 설문(4) - 甲이 제출한 국어번역문과 청구범위의 흠결 및 해소방안

##### 1. 甲이 제출한 국어번역문의 흠결

###### (1) 명세서 배경 기술의 기재(§ 42③(2))

①출원인은 발명의 설명에 배경기술의 구체적 설명 및 상기 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보를 기재하는 것이 원칙이다. 다만, 선행기술문헌 정보의 기재를 강제할 수는 없으므로 배경기술의 구체적 설명만을 기재한 경우에도 적법한 배경기술 기재로 인정될 수 있다.

②기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, i)인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 ii)적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재해야 한다.

③사안의 경우, 甲은 발명의 설명에 i)한국특허공보 7호와 관련된 문헌 정보를 기재하지 않았고 ii)배경기술인 스마트폰 구동시스템에 대한 구체적인 설명을 충분히 기재하였다고 보기도 어려워, 명세서 배경 기술을 적법하게 기재하지 않은바 § 42③(2)의 흠결이 존재한다.

###### (2) § 42③(1)의 하자가 존재하는지 여부

①발명의 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재해야 한다(§ 42③(1)).

②사안의 경우, 원문에는 “지문인식시스템(D)”을 “유전자지문인식시스템(d)으로 구성”하는 구체적인 내용을 기술하고 있는데, 번역문에서는 상기 나머지 내용은 동일하게 기재하면서도 “유전자지문인식시스템(d)”을 “생체지문인식시스템(d)”으로 잘못 기재하고 있는바, 발명의 설명에 기재된 내용에 의해 “생체지문인식시스템(d)”을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 甲의 출원에는 § 42③(1)의 하자가 존재한다.

###### (3) 신규사항 추가금지(§ 47②)의 하자가 존재하는지 여부

①전술한 것과 같이, 출원인이 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(§ 42의 3⑤본문).

②또한, 외국어 특허출원 명세서를 출원서에 최초로 첨부된 명세서로 보고 그 외국어 명세서 범위에서 보정할 수 있도록 하고 있다.

③사안의 경우, 원문에는 “유전자지문인식시스템(d)”만이 기재되어 있는 반면, 보정서

로 취급되는 번역문에는 “생체지문인식시스템(d)” 이 기재되어 있으므로, 이는 최초로 첨부된 명세서 내에서 보정한 것이 아니다. 따라서 甲의 출원에는 § 47②이 흠결이 존재한다.

## 2. 청구범위의 흠결 - 42④(1)의 하자가 존재하는지 여부

① 42④(1)에 따라 청구범위에 기재된 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.

② 원문에는 “지문인식시스템(D)” 을 “유전자지문인식시스템(d)으로 구성” 하는 구체적인 내용을 기술하고 있는데, 번역문에서는 상기 나머지 내용은 동일하게 기재하면서도 “유전자지문인식시스템(d)” 을 “생체지문인식시스템(d)” 으로 잘못 기재하고 있는바, 청구범위에 기재된 “생체지문인식시스템(d)” 부분이 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 보기 어렵다. 따라서 甲의 출원에는 § 42④(1)의 하자가 존재한다.

## 3. 甲의 조치

### (1) 문제점

①전술한 것과 같이, 甲의 출원에는 § 42③(2), § 42③(1), § 42④(1) 및 § 47②의 하자가 존재한다.

②먼저, § 42③(2) 하자와 관련하여, 甲은 명세서의 적절한 배경기술이 개시된 선행기술 문헌의 정보를 추가하는 보정을 함으로써 당해 거절이유를 극복할 수 있다.

③또한, § 42③(1), § 42④(1) 및 § 47②의 하자는 “생체지문인식시스템(d)” 을 “유전자지문인식시스템(d)” 으로 변경하는 보정을 통해 당해 거절이유를 극복할 수 있다.

④이하에서는, 국어번역문의 제출기간이 경과하였는지 여부를 구분하여 甲의 보정 조치를 서술한다.

### (2) 국어번역문의 제출기간이 경과하지 않은 경우

①국어번역문을 제출한 출원인은 국어번역문의 제출시기 이전의 경우에는 i)명세서 또는 도면을 보정하거나 ii)출원인이 심사청구를 한 경우를 제외하고는 미리 제출한 국어번역문에 갈음하여 새로운 국어 번역문을 제출할 수 있다(§ 42의 3③).

②따라서 甲은 “생체지문인식시스템(d)” 을 “유전자지문인식시스템(d)” 으로 변경한 새로운 번역문을 당해 국어번역문의 제출기간 이내에 제출할 수 있다.

③또한, 최종 국어번역문 이전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 42의 3⑤ 단서).

④따라서 “생체지문인식시스템(d)” 이 포함되어 있던 보정은 없었던 것이 되고, “유전자지문인식시스템(d)” 을 포함하는 번역문에 따라 甲의 출원은 보정서를 제출한 것으로 취급될 것이다.

### (3) 국어번역문의 제출기간이 경과한 경우의 조치

①국어번역문에 오역이 있으면 명세서를 보정할 수 있는 기간(§ 47①)에 오역 정정이 가능하다.

②따라서 “생체지문인식시스템(d)” 을 “유전자지문인식시스템(d)” 으로 변경하는 오역의 정정을 할 수 있다.

③다만, 오역의 정정에 따라 정정된 국어번역문에 대해서는 명세서 보정 효과가 부여되지 않는다.

④따라서 甲은 별도로 “생체지문인식시스템(d)” 을 “유전자지문인식시스템(d)” 으로 변경하는 보정서를 별도로 제출해야 할 것이다.

## [문제 - 2]

### I. 설문(1) - 甲의 적극적 권리범위확인심판의 청구이유

#### 1. 특허권의 권리범위해석방법

보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지며(§ 97), 청구범위를 기준으로 구성요건완비의 원칙(AER), 공지기술인지여부, 출원경과참작, 발명의 설명을 참작하여 보호범위를 정한다.

#### 2. PBP 청구항과 관련된 논점

PBP 청구항이 등록된 경우 청구범위에 기재된 방법으로 보호범위를 한정해야하는지 문제되나, 본 문제에서는 방법이 B로 동일하므로 논의의 실익이 없다.

#### 3. 권리범위 관련, 독립항과 종속항 간의 관계

(1) 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항을 종속항이라고 한다.

(2) 권리범위와 관련하여, 독립항은 특허발명으로서 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하고, 종속항은 그 범위 속에서 구체화된 유형을 제시하여 독립항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 사항을 기재하여야 한다. 적법하게 기재된 종속항은 독립항과 비교하여 구체화된 반면, 더 좁은 권리범위를 갖게 된다(다기재협범위의 원칙).

(3) 따라서 제2항의 권리범위를 살펴보면, 물질 A는 물질 a로 구성된다고만 기재되어 있지만 전술한 종속항의 성질에 따라 인용하고 있는 제1항의 B방법에 의하여 제조되는 제조제 P의 구성까지 모두 고려해야 한다.

#### 4. 甲의 적극적 권리범위확인심판의 청구이유

甲은 i)구성요건완비의 원칙에 따라 乙이 실시하고 있는 발명은 자신의 청구범위에 기재된 발명을 그대로 포함한다는 사실을 청구이유에서 주장할 것이다. ii)더 나아가 독립항 및 종속항의 관계에서 종속항인 제2항의 발명은 제1항의 발명의 기술적 특징을 그대로 가지면서 구체화된 더 좁은 권리범위를 갖게 되고, 乙이 실시하고 있는 발명은 종속항인 제2항의 발명에 해당되므로, 甲은 乙의 실시가 자신의 권리범위에 속한다는 내용으로 청구이유를 구성할 수 있다.

### II. 설문(2) - 乙 무효심판의 청구이유

#### 1. PBP 청구항 기재방식에 따른 무효사유를 주장할 수 있는지 여부

(1)구법 상 심사 실무는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우에 한하여 PBP 청구항의 개재를 인정하고, 용이하게 기재할 수 있음에도 방법적으로 기재한 경우에는 § 42④(3) 위반사유가 있는 것으로 취급하였다.

(2) 단, 개정법에서는 i) § 42⑥에서 ‘방법’의 기재를 인정하고 있고 ii) § 42④(3)를 삭제하였는바 일반적으로 PBP 청구항의 기재를 허용하고 있다.

(3) 따라서 乙이 명세서 기재불비의 무효사유를 주장하는 것은 어렵다고 판단된다.

## 2. 신규성 및 진보성의 무효사유를 주장할 수 있는지 여부

### (1) 신규성(§ 29①각호) 및 진보성(§ 29②)

①출원 전 국내/외에서 공지 등이 된 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없다. 이는 i)신규한 발명을 공개한 자에 대하여만 공개의 대가로서 특허권을 부여하고 ii)공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

②발명의 진보성이란 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 § 29① 각호의 어느 하나에 규정된 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 주관적 창작성을 말한다(§ 29②). 이는 공지기술보다 비약적이고 누진적인 발명에 대해서만 특허를 허여하기 위함이다.

### (2) PBP 청구항의 신규성 및 진보성의 판단방법

1)청구범위에 방법과 물건이 함께 포함되므로 등록요건을 판단하는 경우 PBP 청구항의 등록여부 판단대상 확정과 관련하여 이하 논해본다.

2)학설은 ①청구범위의 해석원리에 따른 것으로 생산방법에 의하여 실제로 생산된 물건에만 권리가 미친다는 한정설과 ②PBP 청구항은 물건을 특정하기 위한 수단으로 다른 방법에 의해 생산된 물건에도 권리가 미친다는 동일성설이 대립된다.

3)심사 실무는 보호 받고자 하는 권리는 방법이 아니라 물건자체로 해석하여, 진보성 등에 대한 판단대상은 물건으로 보고 심사하고 있다.

4)종래 대법원 判例는, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 없는 한, 보성 유무를 판단함에 있어 제조방법은 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전의 공지기술과 대비하여 판단하면 된다고 판시하였다.

5)최근 전원합의체 判例는, PBP 청구항의 경우 청구범위에 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하며, 청구하고자 하는 발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건이므로, 제조방법으로 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재를 포함해 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 특허요건을 판단해야 한다고 판시하였다.

6)생각건대 i)제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질은 ‘물건의 발명’이고, ii)청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하

는 하나의 수단으로서의 의미를 가질 뿐이므로, 제조방법의 기재를 제조방법의 기재를 포함해 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 신규성 또는 진보성 등의 특허요건을 판단하는 최근 判例의 태도는 타당하다.

### (3) 사안의 경우

① i) 제1항에서 B방법은 A로 구성된 제조제를 특정하는 수단으로만 이용되어야 하고, ii) 선행문헌에 “A로 구성되며 C 방법에 의해 제조되는 P”가 기재되어 있어 C 방법과 상관없이 A로 구성된 P가 개시되어 있으므로, 甲의 제1항 발명은 신규성을 상실한 발명이 된다.

② 한편, i) 신규성이 인정되는 발명에 대해 진보성 인정여부를 판단하는 것이 타당하고 ii) B 방법이 C 방법보다 진보성이 있더라도 전술한 것과 같이, 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서의 의미를 가질 뿐이므로, 진보성이 인정되기도 어렵다.

③ 따라서 乙은 C 방법과 상관없이 물질 A로 구성된 제조제 P는 선행문헌에 개시되어 있다는 이유로 甲의 특허발명에 신규성의 하자가 있다고 청구이유를 구성할 수 있다.

## Ⅲ. 설문(3) - 신규성 판단기준에 따른 무효심판의 청구이유

### 1. 신규성의 판단기준

(1) 출원발명과 인용 발명 간의 구성을 대비하여 구성의 일치점과 차이점을 추출하여 동일성을 판단하며 청구항이 2 이상인 경우 청구항마다 판단하고 발명의 효과를 참작한다.

(2) 判例는 특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고, 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 안된다고 판시하였다.

(3) 사안의 경우, 1개의 인용문헌을 근거로 신규성을 판단하되, 동일성 판단과 관련하여 “D시스템”과 “H시스템”이 상이하고 “보존용기 K”와 “보존용기 K1”이 상이하므로, 인용문헌에 기재된 발명과 제3항에 기재된 발명이 실질적으로 동일한지 여부를 설명한다.

### 2. 발명의 동일성의 판단방법

(1) 判例는 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일성이 있다고 판시하였다.

(2) 또한, 判例는 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로 대비되

는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다고 판시하여, 실질적 동일성 개념을 인정하고 있다.

### 3. 부분적으로 구성이 일치하는 경우의 실질적 동일성 판단 방법

判例는 전후로 출원된 양 고안이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 고안을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 고안이 신규의 고안과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 고안이 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 고안은 동일하다 할 것이고 비록 양 고안의 구성에 상이점이 있어도 그 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 고안의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니 하는 경우에는 양 고안은 역시 동일한 고안이라고 판시하였다.

### 4. 사안의 경우

(1) 제3항 발명과 인용문헌에 기재된 발명을 비교하면, “D시스템” 과 “H시스템” 이 상이하고 “보존용기 K” 와 “보존용기 K1” 이 상이하다는 차이점이 있으나 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 동일할 수 있다. 따라서 甲은 청구이유에 실질적 동일을 근거로 신규성이 없음을 기술할 수 있다.

(2) 또한, 甲은 判例의 입장에 따라 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 고안을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 고안이 신규의 고안과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 고안이 되는 등의 특별한 사정이 없다는 것을 밝혀, 실질적 동일성을 주장할 수도 있다.

### [문제 - 3]

#### I. 설문(1) - 조약우선권 주장의 요건

##### 1. 주체적 요건

i)대한민국 국민, 동맹국 국민 및 준 동맹국 국민이 우선권 주장을 할 수 있고 ii)우선권 주장 출원인은 선출원의 출원인과 동일인이거나 정당 승계인이어야 한다. 다만, 우선권의 독립성에 기인하여 승계인은 선 출원을 승계하였다 하더라도 우선권을 별도로 승계 받아야 한다.

##### 2. 객체적 요건

###### (1) 출원의 최선성

①우선기간이 연장되어 존속기간이 실질적으로 연장되는 결과를 방지하기 위해 우선권 주장의 기초가 되는 출원은 동맹 제1국의 최초 출원이어야 한다.

②다만, i)후속출원이 같은 국가에서 같은 대상에 대해 출원되고 ii)후속출원의 출원 이전에 최선 출원이 취하, 포기 또는 거절되며 iii)최선출원이 공개되지 않았고 iv)최선출원에 의해 어떠한 권리도 존속되지 않으며 v)최선출원이 같은 국가 또는 타국에서 아직 우선권 주장의 기초가 되지 않은 경우에는 후속출원을 기초로 우선권 주장을 할 수 있다(파리조약 4C(4)).

###### (2) 출원의 정규성

일단 정규의 출원으로 인정되면 그 출원이 무효, 취하, 포기 등이 된 경우에도 이를 기초로 우선권 주장을 할 수 있다.

###### (3) 형식의 무제한

형식에 상관없이 조약 우선권 주장이 가능하나 상표출원을 기초로 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 우선권을 주장하는 것은 성격상 부합하지 않다.

##### 3. 시기적 요건

우선 기간 내에 우선권 주장하며 출원하여야 하는데, 출원인의 이익과 일반 3자의 이익의 조화 관점에서 특허 및 실용신안은 1년, 디자인 및 상표에 대해서는 6월로 규정하고 있다(파리조약 4C(1), § 54②).

#### II. 설문(2) - 조약우선권 주장 출원의 발명의 동일성 판단

### 1. 조약우선권 주장 출원의 인정 근거

조약에 의한 우선권 제도는 파리조약상의 우선권 제도가 기본적으로 적용되고, 그 밖에 파리조약의 비동맹국이라고 하더라도 우리나라와 조약에 의하여 상호 우선권을 인정하기로 한 국가의 경우에도 적용이 된다.

### 2. 조약우선권 주장에서의 발명의 동일성 판단(파리조약 4H)

(1) 우선권을 주장하기 위해서는 출원의 목적물이 동일성을 가져야 한다. 목적물이 동일성을 가지는 경우라 함은 동맹 제1국에서의 출원의 목적물이 동맹 제2국에 있어서의 목적물과 그 실질적인 요지에 있어서 동일성을 가지는 경우를 말한다.

(2) 判例도 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 최초 명세서 또는 도면에 기재된 것과 문언상으로 동일한 발명 뿐만이 아니라, 그와 기술적 구성이 실질적으로 동일한 발명을 포함한다고 판시하였다.

(3) 다만, 후출원에서 동일성이 없는 발명이 기재되어 있는 경우, 조약우선권주장출원 전체가 부적법하게 되는 것은 아니고 동일성이 인정되는 발명만 우선권의 이익을 향유하고, 그 이외의 발명은 우리나라 출원일을 기준으로 특허요건 등을 심사하게 된다.

### 3. 조약우선권 주장에서의 동일성 판단 대상(파리조약 4H)

(1) 목적물의 동일성 판단은 청구범위의 기재 뿐만 아니라 출원서/명세서 및 도면 등 출원서류 전체의 기재에 의하여 거기에 개시되어 있는 기술적 사상을 바탕으로 하여 실질적으로 판단하여야 하며, 비록 우선권의 주장에 관련된 것이 동맹 제1국의 출원에서 청구범위에 기재되어 있지 않더라도 출원서류 전체에 의하여 그 구성부분이 개시되어 있기만 하면 우선권을 부인하여서는 안된다는 의미이다.

(2) 즉, 선출원의 “최초” 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의해 삭제된 발명을 기초로도 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원의 청구범위가 보정된 경우에는 보정 후에 최종적으로 확정된 청구범위를 기준으로 우선권 주장의 적법성을 판단하게 된다.

### 4. 조약우선권의 유형 및 동일성 판단 방법 (파리조약 4F)

(1) “복합우선”이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권을 주장하는 것을 말하고, “부분우선”이란 1 또는 그 이상의 우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 않는 일 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것을 말한다.

(2) 동맹국은 출원인이 부분우선 또는 복합우선을 한다고 하여 당해 우선권 또는 특허신청을 거절할 수 없다. 다만, 동맹국의 법령상 발명의 단일성이 있는 경우에 한하며, 우리나라 특허법의 해석상 우선권주장출원이 발명의 단일성이 인정되지 않는 경우에는 특허법 제45에 의해 거절이유를 통지할 수 있다.

(3) 우선권이 주장되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대하여는 후출원일을 기

준으로 특허요건 등을 판단하게 한다.

## 5. 사안의 경우

(1) 일본과 대한민국은 파리조약의 동맹국으로서, 조약에 의한 우선권 제도는 파리조약상의 우선권 제도가 기본적으로 적용된다.

(2) 甲은 특허출원 1 및 특허출원 2에 대해 우선권 1 및 우선권 2를 주장하여 복합우선 또는 부분우선을 하고 있으나 개별적으로 우선권을 판단하여 우선권이 주장되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대하여는 후출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하고, 포함된 구성요소에 대해서는 소급하여 특허요건 등을 판단하면 된다.

(3) 또한, 동일성의 판단은 특허출원 1의 “최초 명세서 또는 도면”에 기재된 내용과 대한민국 특허출원의 청구범위에 기재된 발명을 비교하면 된다. 또한, 특허출원 2의 “최초 명세서 또는 도면”에 기재된 내용과 대한민국 특허출원의 청구범위에 기재된 발명을 비교하면 된다.

(4) 또한, 대한민국 특허출원의 청구범위에 기재된 발명과 특허출원 1 또는 특허출원 2에 기재된 발명을 비교함에 있어서, 동일성은 문언상으로 동일한 발명 뿐만이 아니라, 그와 기술적 구성이 실질적으로 동일한 발명을 포함하여 판단하면 된다.

## Ⅲ. 설문(3) - 인용문헌이 신규성 판단의 선행문헌에 해당하는지 여부

### 1. 甲의 우선권 주장의 요건 검토

i) 甲은 대한민국 국민으로 선출원의 출원인과 동일하므로 주체적 요건은 만족하고 ii) 기초출원이 최선의 출원으로 정규성 및 형식도 만족하며 iii) 1년의 시기적 요건도 만족한다. iv) 출원과 동시에 우선권 주장을 하였고, 일본에서의 출원번호를 기재한 서면을 제출하였다면 甲의 우선권 주장 출원은 요건과 절차를 만족할 것이다.

### 2. 우선권 주장의 효과(파리조약 4B)

우선권 주장이 적법한 경우, i) 우선권 주장 기간 중에 행하여진 행위, 특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시, 당해 디자인으로 된 물품의 판매 또는 당해 상표의 사용으로 인하여 무효로 되지 아니하며 ii) 이러한 행위는 3자의 권리 또는 개인 소유의 권리를 발생시키지 아니한다. iii) 파리조약 제4조 B는 특허요건(§ 29), 선출원(§ 36), 이용/저촉 관계(§ 98), 생산방법 추정(§ 127) 등을 판단할 때 선출원을 기준으로 한다는 것을 의미한다.

### 3. 우선권 주장에 따른 효과 및 선행문헌에 해당할 수 있는지 여부

#### (1) A와 B를 결합하여 하나의 청구항에 기재한 경우

①설문(2)에서 전술한 것과 같이, 복합우선의 경우에는 각 선출원의 최초 명세서 및 도면과 후출원의 청구범위를 개별적으로 비교하여 발명의 동일성을 판단한다.

②특허출원 1에는 A만이 기재되어 있을 뿐 A+B가 기재되어 있지 않고, 특허출원 2에도 A와 B가 구분되어 기재되어 있을 뿐 A와 B가 결합된 발명이 개시되어 있지 않으므로, 발명의 동일성이 각각 인정되지 않는다.

③따라서 A와 B를 결합하여 하나의 청구항에 기재한 경우에는 대한민국 특허출원일이 등록요건의 판단시점이 되고, 인용문헌은 신규성을 판단하는 선행문헌에 해당한다.

#### (2) A와 B를 다른 청구항으로 분리하여 기재한 경우

①특허출원 1에는 B가 기재되어 있지는 않지만 A가 기재되어 있으므로, A 또는 B 중 공통된 A는 특허출원 1의 출원일로 판단시점이 소급된다.

②특허출원 2에는 A와 B가 모두 기재되어 있고, A와 B 모두 특허출원 2로 판단시점이 소급될 수 있으나 특허출원 1에 대한 우선권 주장의 효과를 향유하여, 결국, A의 판단시점은 특허출원1의 출원일이 되고, B의 판단시점은 특허출원2의 출원일이 된다.

③따라서 인용문헌은 A 발명에 대해서는 신규성을 대비 판단하는 선행문헌에 해당하지 않고, B 발명에 대해서는 선행문헌에 해당한다.

#### (3) 인용문헌이 후 출원의 신규성을 대비 판단하는 선행문헌에 해당할 수 있는지 여부

① 甲은 A와 B를 분리하여 다른 청구항에 기재하고 있으므로, A의 판단시점은 특허출원1의 출원일이 되고, B의 판단시점은 특허출원2의 출원일이 되며, 인용문헌은 A 발명에 대해서는 신규성을 대비 판단하는 선행문헌에 해당하지 않고, B 발명에 대해서는 선행문헌에 해당한다.

② 따라서 제1항의 A발명은 인용문헌으로부터 신규성 등이 전혀 문제되지 않는다. 제2항의 B 발명은 인용문헌이 선행문헌에 해당하고, 신규성은 문제되지 않으나 진보성이 문제될 수 있다.

## [문제 - 4]

### 1. 설문(1) - 실시권자가 이해관계인에 해당하는지 여부

#### 1. 무효심판의 청구인

무효심판의 청구인은 이해관계인 또는 심사관이다. 심판청구의 난립을 방지하고 심판사권의 적체를 해소하는 한편 산업질서의 안정화를 도모하기 위해 이해관계가 있는 자가 심판을 청구할 수 있도록 하고 있다.

#### 2. 이해관계인

(1) 判例에 따르면, 이해관계인이란 당해 특허발명과 동종의 물품을 제조, 판매하거나 제조, 판매할 염려가 있는 자로서 당해 특허발명의 권리 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이에겐 장차 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함된다.

(2) 판단시점과 관련하여, 判例는 심결시를 기준으로 이해관계가 있는지 여부를 판단하고 있다.

#### 3. 실시권자가 이해관계인에 해당하는지 여부

(1) 특허권자와 통상 실시권자는 기술과 자본의 결합과 같은 형태 및 강력한 신뢰를 바탕으로 한 공동체적 관계를 형성하는 경우가 많으므로, 통상 실시권자를 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로서 인정할 수 있는지 여부가 문제된다.

(2) 학설은 i)신의칙 및 대항받을 가능성이 없다는 이유로 이해관계를 부정하자는 견해와 ii)무효심판의 진정한 취지 및 실시료 면제의 이익에 따라 이해관계를 긍정하자는 견해 등이 있다.

(3) 判例는 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여 받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 판시하였다.

(4) 단, 判例는 특허무효심판청구인이 특허청으로부터 본건 특허의 통상실시권을 허여받았다 하여도 동 허여처분에 제품 순 판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 통상 실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 한다면 위 실시권 허여 자체만으로 당사자 간의 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으니 특허무효심판을 구할 이해관계가 있다고 판시하였다.

(5) 생각건대 일률적으로 판단할 것이 아니라, 사안에 따라 특허권 소멸에 따라 자신의 권리, 의무에 직접적 영향 미치면 이해관계 긍정함이 타당하다. 즉, i)신의칙 ii)대항 받을 가능성 iii)실시료 면제의 이익이 있는지 등을 고려하여 구체적인 사건에 따라 이해관

계 인정 여부를 판단하는 것이 타당하다.

#### 4. 乙이 이해관계인에 해당하는지 여부

사안에서, i)甲과 乙이 계약을 통해 부쟁의 합의까지 한 것으로는 볼 수 없어 무효심판청구행위가 신의칙에 반한다고 볼 수 없고 ii)제품 매출액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 한다는 특별한 사정 등을 고려할 때, 乙의 이해관계인 적격을 인정하는 것이 타당하다.

## II. 설문(2) - 이미 지급된 특허사용료에 대한 부당이득반환청구가 가능한지 여부

### 1. 확정된 무효심결의 효과 및 계약자유의 원칙

(1) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 133①본문). 따라서 甲의 특허권은 처음부터 없었던 것이 되므로 이미 지급된 특허사용료를 부당이득으로 반환해야 하는지 여부가 문제된다.

(2) 계약자유의 원칙에 따라 甲과 乙 간에 별도의 계약이 존재하는 경우에는 정해진 계약에 따라 부당이득에 대한 문제가 해결될 수 있다. 그러나 사안에서는 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 처리해야 할 것인지와 관련하여 협의하지 않았으므로, 이하에서는 일반 원칙에 따라 상기 문제를 해결하고자 한다.

### 2. 무효가 확정된 특허권에 대해 부당이득으로서 실시료 반환청구가 가능한지 여부

#### (1) 학설

①실시료를 지불하였더라도 발명을 실시하여 이익을 얻었는바 손해를 입은 것이 아니므로 부당이득의 법리를 적용할 수 없다고 보는 견해, ②실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 자유기술영역의 실시로 인해 얻은 이익이므로 누구나 취할 수 있는 것인바 부당이득반환 청구를 긍정하는 견해, ③무효된 경우의 취급에 대한 특별한 계약이 있는 경우를 제외하고는 부당이득의 법리를 적용할 수 없다고 보는 견해 등이 대립된다.

#### (2) 判例

특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허 실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

### (3) 검토

생각건대 i)특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 되고 ii)특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적/배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어볼 때, 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무는 없다고 보는 것이 타당하다(절충적 견해).

### 3. 甲이 특허사용료를 부당이득으로 반환해야 하는지 여부

i)특허 실시계약의 대상인 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 할 건인지에 관한 내용을 계약에 특별하게 포함시키지 않았고, ii)특허가 무효되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적/배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되어 乙은 반사적 이익을 취했다고 판단되므로, 甲이 이미 지급받은 특허사용료를 부당이득으로 반환할 의무는 없다고 판단된다.

### Ⅲ. 결론 - 이해관계 폐지론

i)실질적으로 이해관계 없는 자가 심판을 청구하는 경우는 드물고 ii)이해관계 유무조사가 오히려 심판지연의 문제를 초래할 수 있어 이해관계 규정의 취지인 심판청구 남용방지, 심판사건의 적체해소가 무색해질 수 있다는 점을 고려하여, 이해관계를 폐지하는 것이 타당하다고 보는 견해가 있다.